

<제8장 근로관계의 종료.제3절 해고의 절차적 정당성>

I. 서설

- 해고는 근로자의 신분을 박탈하는 중대한 인사 처분이므로, 근로기준법은 해고의 실체적 정당성 외에도 절차적 정당성을 엄격하게 요구하여 근로자의 방어권을 보장하고 사용자의 자의적인 해고를 방지한다. 해고의 절차적 정당성이란 해고 처분을 함에 있어 법령 또는 노사 간의 자치규범(단체협약, 취업규칙)에서 정한 특정 절차를 준수해야 함을 의미한다. 판례는 절차적 정당성의 준수 여부가 해고의 유효 요건이라고 보며, 절차적 위반이 있을 경우 해고는 실체적 정당성 유무와 관계없이 무효가 된다고 판단한다.

II. 법령상 해고의 제한

1. 해고의 예고[근기법 제26조]

(1) 해고예고의 의의

- 근로기준법 제26조 본문은 사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다.고 규정한다. 이는 근로자가 해고에 대비하여 새로운 직장을 구할 수 있도록 시간적 여유를 주거나, 그에 상응하는 경제적 보상을 제공함으로써 근로자의 생활 안정을 도모하기 위함이다.

(2) 해고예고의 예외

- 근로기준법 제26조 단서는 다음과 같은 경우 해고예고 의무를 면제한다. ① 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우 ② 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우 ③ 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령(근로기준법 시행규칙 제4조 별표1)으로 정하는 사유에 해당하는 경우.

2. 해고의 서면통지[근기법 제27조]

(1) 의의

- 근로기준법 제27조 제1항은 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.고 규정한다. 이는 해고 사유 등의 내용을 명확하게 하여 근로자의 방어권 행사를 용이하게 하고, 해고를 둘러싼 분쟁을 사전에 예방하며, 해고의 존재 및 범위를 명확히 하기 위함이다.

(2) 통지의 방식 및 효과

① 서면 통지 의무

- 해고 통지는 원칙적으로 구두나 단순한 문자 메시지가 아닌 서면(문서)으로 이루어져야 한다. 다만, 예외적으로 서면에 의한 해고통지의 역할과 기능을 충분히 수행하고 있는 이메일이나 문자 메시지라면 인정이 될 수 있다.

② 위반의 효과

- 근로기준법 제27조 제2항은 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.고 명시하고 있다. 따라서 서면 통지 의무를 위반한 해고는 실체적 정당성 유무와 관계없이 무효가 된다.

3. 해고시기의 제한[근로기준법 제23조 제2항]

- 근로기준법 제23조 제2항은 근로자의 생활 보호 및 근로자에게 불리한 시기에 해고하는 것을 방지하기 위해 해고 시기에 대한 제한을 규정한다.

(1) 업무상 재해·질병 기간

- 근로자가 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일간은 해고할 수 없다.

(2) 산전후 휴가 기간

- 출산 전후 휴가 기간과 그 후 30일간은 해고할 수 없다.

(3) 예외

- 위 기간 동안에도 사용자가 일시보상을 하거나, 사업을 계속하는 것이 불가능하다고 인정된 경우에는 해고가 가능하다.

4. 관련 판례(해고가 무효인 경우에 해고예고수당의 반환청구 거부)

(1) 문제의 소재

- 사용자가 해고예고 없이 해고예고수당을 지급하였으나, 해당 해고가 부당해고로 판정되어 무효가 된 경우, 사용자가 근로자에게 이미 지급한 해고예고수당을 부당이득으로 반환 청구할 수 있는지 문제된다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 해고예고수당의 지급 의무는 해고의 효력 유무와 관계없이 해고 예고 의무 위반에 따른 법적 의무 이행으로 발생한 것이라고 본다. 따라서 해고가 무효가 되어 근로자가 복직하고 해고 기간 동안의 임금(백 पेи)을 지급받게 되더라도, 이는 근로계약의 존속에 따른 임금 채권의 이행일 뿐, 해고예고수당과는 성격이 다르다고 본다.

(3) 결론

- 사용자는 해고가 무효로 된 경우에도 이미 지급한 해고예고수당을 원칙적으로 반환 청구할 수 없다. 다만, 지급된 해고예고수당이 백 पेи와 중복되는 경우에는 임금에서 상계될 수 있을 뿐이다. 즉, 해고예고수당은 예고를 하지 않은 것에 대한 제재적 성격을 갖는다고 이해한다.

III. 자치규범에서 정한 해고사유의 절차적 정당성

1. 해고의 절차적 정당성

(1) 의의

- 단체협약이나 취업규칙 등 노사 간의 자치규범에서 해고에 관한 특정 절차를 규정하고 있는 경우, 사용자는 비록 법령에 명시되지 않은 절차라 하더라도 이를 반드시 준수해야 한다. 이러한 절차는 주로 징계위원회 개최, 근로자의 소명(변명) 기회 부여, 노동조합과의 사전 협의 등의 형태를 취한다.

(2) 위반의 효과

- 판례는 단체협약이나 취업규칙에 정한 해고 절차 규정은 근로자의 방어권 보장이라는 강행적 의미를 가지므로, 이러한 절차 규정을 위반하여 행해진 해고는 실체적 사유가 인정되더라도 무효가 된다고 일관되게 판시한다.

2. 징계해고사유와 통상해고사유에 모두 해당하는 경우

(1) 문제의 소재

- 근로자의 행위가 징계해고사유(비위 행위)와 통상해고사유(능력 부족 등)에 동시에 해당하는 경우, 사용자가 징계 절차를 회피하기 위해 통상 해고의 형식을 취한 경우, 절차적 정당성 위반 여부가 문제된다. 징계 해고는 통상 징계위원회 회부, 소명 기회 부여 등 엄격한 절차를 요구하는 경우가 많다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 근로자의 비위 행위에 대해 징계 해고 절차가 규정되어 있음에도 불구하고, 사용자가 이를 회피할 목적으로 통상 해고의 형식을 취하여 징계 절차를 거치지 않았다면, 이는 절차적 정당성을 위반한 것으로 보아 무효라고 판단한다. 이는 실질적으로 징계의 목적을 가진 해고라면 징계 절차를 준수해야 근로자의 방어권이 보장될 수 있기 때문이다.

IV. 결론

- 해고의 절차적 정당성은 실체적 정당성과 더불어 해고의 유효 요건을 구성한다. 사용자는 근로기준법이 정한 해고예고(또는 수당 지급), 서면 통지, 해고시기 제한을 준수해야 하며, 단체협약이나 취업규칙에서 정한 징계위원회 회부 및 소명 기회 부여 등 자치 규범상의 절차도 강행적으로 준수해야 한다. 이러한 절차적 정당성의 결여는 해고를 무효로 만드는 결정적인 사유가 된다.